

1502973-78.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Cesar Ribeiro

Comarca: Santa Rosa de Viterbo

Foro: Foro de Santa Rosa de Viterbo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... não repercuta relevantemente na redução do tráfico de drogas e não gera danos às organizações criminosas.

Este Juízo entende que o benefício do "tráfico privilegiado" não se aplica apenas àquele agente que traficou droga uma única vez, pois não é essa exigência feita pela lei penal. Exige-se apenas que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rosa de Viterbo

Vara Única

Rua Francisco Carvalho de Andrade, 121, Centro - Santa Rosa de Viterbo-SP

cep 14270-000 - Telefone: (16)3954-1506 - E-mail: santarosa@tjsp.jus.br

Processo Digital nº 1502973-78.2021.8.26.0530 - lauda de

SENTENÇA

Processo Digital nº 1502973-78.2021.8.26.0530

Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento(s) de origem: Boletim de Ocorrência: 1359/2021, Inquérito Policial (Flagrante): 234979-17/2021

Autor: Justiça Pública

Réu: CLÁUDIO ROGÉRIO DO NASCIMENTO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação penal contra Cláudio Rogério do Nascimento, vulgo "Claudião", por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia (fls. 80/81), no dia 23 de dezembro de 2021, por volta da 20h45, na Rua José Val nº 147, nesta cidade e comarca de Santa Rosa de Viterbo, o acusado guardava e trazia consigo, sem autorização legal, para fim de entrega a consumo de terceiros (para fim de tráfico), 16 eppendorfs de cocaína com 2,590 gramas; tratando-se de droga de uso e comércio proscritos no Brasil. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial (fls. 01/74).

O réu foi preso em flagrante delito, mas houve concessão de liberdade provisória por decisão do Plantão Judiciário (fls. 48/52).

Laudo pericial das drogas a fls. 100/102.

Adotado o rito da Lei de Drogas (fls. 83); o acusado foi notificado (fls. 93) e não constituiu advogado. Nomeado, Defensor dativo que apresentou defesa prévia (fls. 97/99), rejeitada a fls. 105/2016 em 18/03/2022, por decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

Citação a fls. 132.

Durante da instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 136/137 e mídia) e o réu foi interrogado (fls. 138 e mídia).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, indeferimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e fixação do regime inicial fechado de cumprimento da

pena de reclusão (fls. 135 e mídia).

A Defesa sustentou, nos debates, a desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio, e, em caso de condenação pelo crime imputado, requereu a fixação das penas no mínimo, com reconhecimento da atenuante, aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixação do regime aberto de cumprimento de pena e aplicação de penas alternativas (fls. 135 e mídia).

Relatados.

Não há preliminares. A ação penal teve regular trâmite.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo laudo de exame toxicológico de fls. 100/102, complementado pelo laudo de constatação de fls. 16/18, que verificaram a presença do princípio ativo da cocaína em 16 microtubos (ou eppendorfs) de cor laranja com 2,590 gramas.

Nenhuma das partes apresentou impugnação quanto à prova pericial, e esta prova foi formalmente e materialmente perfeita, porquanto realizada pelo Instituto de Criminalística, e subscrita por perito oficial.

A autoria também está suficientemente demonstrada.

Na fase policial (fls. 06), ao ser preso em flagrante delito, o réu confessou a autoria criminoso, dizendo ter filhos presos, não ter condições financeiras, e que estaria se dedicando ao tráfico de drogas como única forma de prover às suas despesas de subsistência. Confirmou que as 16 porções de cocaína apreendidas lhe pertenciam e eram destinadas à venda; levava consigo uma porção de cocaína no momento da abordagem policial, e as demais estavam guardadas em sua casa. Vendia cada porção por R\$ 20,00 e já havia vendido algumas porções na data de sua prisão, sendo oriundo o dinheiro apreendido consigo e em sua casa a partir da venda de entorpecentes. Autorizou acesso aos dispositivos de telefone celular.

Em Juízo (fls. 138 e mídia), o réu alegou que nunca foi preso ou processado criminalmente; trabalhava como "saqueiro" (carregador de sacos); é casado e tem quatro filhos, sendo um deles menor de idade. É usuário de cocaína há mais de cinco anos. Admite que estava com um pino cocaína e que usaria essa droga no Bar do Gilmar, quando foi detido pela Polícia Militar, e disse aos policiais que usaria aquele pino no bar e que um "cara" de Ribeirão Preto teria trazido para o declarante. Após, os policiais foram à casa do acusado e encontraram mais 15 pinos; pois o acusado os autorizou a entrar na casa do réu e disse aos policiais que lá havia mais droga. Esses 15 pinos estavam guardados numa caixa de remédio em cima de uma viga de sua casa, sendo o interrogando quem exibiu a localização das drogas aos PMs. O dinheiro apreendido proveio de benefício previdenciário de afastamento (auxílio-doença) do interrogando. Admitiu que parte da droga que trazia e que guardava em casa seria utilizada, e que outra parte venderia para comprar roupa de Natal para seu filho. Recebia a verba pelo afastamento do trabalho (do INSS), que era insuficiente. Negou tivesse continuado a exercer o tráfico de drogas que seus filhos realizavam, e que, à época, a filha Pietra estava presa, e que Pablo (seu outro filho) não estava preso ao tempo dos fatos. Comprou a droga de um "rapaz" da cidade de Ribeirão Preto, com quem teve contato através de um amigo do depoente. Admite que seu filho Pablo também guardava, outrora, droga na viga de casa; e disse que o acusado guardava na viga da casa para levar as drogas para rapazes cheirarem juntamente com o acusado. Está afastado do serviço de saqueiro e tinha carteira de trabalho registrada, recebendo benefício do INSS. Moravam na casa, à época, o acusado, sua esposa e o filho menor. Deixava a droga naquele local (pillar da casa) porque ali era mais fácil para pegar a cocaína na parte interior da casa. Não estava traficando drogas há dois ou três meses, pois o fazia há pouco tempo. Costumava ficar no meio dos "meninos" que vendiam droga, pois tinha amizade com esses rapazes, estando afastado do trabalho desde 2017 (pois operou a coluna por duas vezes, e não andava). Os valores apreendidos foram de R\$ 350,00 e R\$ 67,00, e provieram do benefício previdenciário do acusado.

A prova testemunhal corrobora a imputação inicial e a confissão do réu.

A testemunha Cássio Funes de Queiroz, policial militar (fls. 03/04, 136 e mídia), informou que realizava patrulhamento de rotina com o PM Eder, e, na data fática, o

Copom da Polícia Militar já havia transmitido para as equipes de serviço, por três vezes, informes recebidos no sentido de "Claudião" estaria traficando drogas nas proximidades do Bar do Mário, no bairro Nosso Teto; onde era procurado por usuários; o réu ia à sua própria casa (que fica perto do bar), e retornava com o entorpecente, entregando-o ao comprador. Foram realizadas diligências pelo local, mas o réu não foi visto no início. Porém, por volta de 20h45, o depoente e o policial Eder retornaram ao bairro e viram o acusado perto do bar referido, e o abordaram. Ele trazia consigo um microtubo contendo porção de cocaína, além de R\$ 67,00 em dinheiro e seu telefone celular. Indagado, o acusado admitiu que a porção de droga que levava consigo lhe pertencia e seria destinada à venda, pois estava com dificuldades financeiras e precisava ganhar dinheiro. Foi inquirido se teria entorpecentes em casa, e informou que havia outras três porções de cocaína. Ele foi conduzido ao imóvel e lá apontou uma caixa de medicamento sobre uma viga de madeira da varanda frontal, onde havia outros 15 eppendorfs com cocaína. Na estante da sala havia R\$ 300,00 em dinheiro, e o réu admitiu ter conseguido esse dinheiro com a venda de cocaína, dizendo vender cada pino por R\$ 20,00 e que já havia comercializado diversas porções no dia, de onde conseguiu o dinheiro apreendido. O réu era alvo de constantes notícias de tráfico de drogas, mas nas abordagens anteriores, embora tivesse consigo dinheiro, não levava entorpecentes.

Na fase judicial (fls. 136 e mídia), o policial Cássio Funes de Queiroz disse que, no dia dos fatos, estava em serviço com o cabo PM Leandro, quando o Copom os informou que o indivíduo conhecido por "Claudião", do bairro Nosso Teto, estaria traficando drogas perto do Bar do Mário; e que o suspeito contatava o usuário, ia à própria residência (do réu), pegava e entregava o entorpecente ao comprador. Feita diligência inicial no local, o réu não foi localizado. Após, houve nova solicitação do Copom em relação ao réu, e, no bairro, o acusado foi localizado, sendo submetido à busca pessoal, e verificou-se que ele trazia um pino de cocaína e R\$ 67,00 em dinheiro, além de um telefone celular. Indagado, de pronto, o réu disse que estaria atravessando dificuldades econômicas, e, por isso, estava traficando drogas. Indagado se em sua casa haveria mais drogas, o réu admitiu lá haver mais três pinos com cocaína; ele levou os policiais à sua casa, que fica três imóveis de distância do local de sua abordagem, e, sobre uma viga de madeira, o próprio réu apontou uma caixa de medicamento que foi apreendida e que continha outros 15 eppendorfs idênticos ao apreendido na abordagem com o réu. Indagado, disse o réu que não havia mais drogas em casa, apenas indicando, na estante da casa, a importância de R\$ 300,00, que foi apreendida porque seria produto da venda de droga. Por isso, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi apresentado na delegacia de polícia. O réu disse aos policiais que tanto os R\$ 67,00 consigo apreendidos quanto os R\$ 300,00 apreendidos na casa eram produto da venda de drogas. Antes das duas notícias recebidas pelo depoente naquela data, cerca de dois meses antes do fato, o depoente recebera informes de que o réu fazia o tráfico de drogas, pois os filhos dele (Pablo e Pietra) foram presos e esses filhos ajudavam o réu nas despesas da casa do acusado; e, diante das prisões desses filhos, o réu deixou de ter renda e passou a traficar. Foi o próprio réu quem franqueou o acesso dos policiais à residência dele. O acusado admitiu que a droga apreendida era destinada à venda.

A testemunha Eder Leandro da Silva, policial militar, na fase extrajudicial (fls. 05), afirmou que, na data fática, patrulhava nesta cidade com o outro policial (Cássio), e, na data fática, o Copom havia transmitido informes de que um indivíduo de apelido "Claudião" estaria traficando drogas perto do Bar do Mário, no bairro Nosso Teto; onde ele era procurado por usuários interessados em comprar drogas, ia até sua casa (do réu), que fica perto do bar, pegava a droga e a entregava aos interessados. Foram realizadas diligências nas proximidades, porém o réu não foi visto durante as incursões iniciais. Por volta de 20h45, o depoente e a outra testemunha retornaram ao bairro viram o acusado perto do bar mencionado, no cruzamento da Avenida Professora Luiza Garcia Ribeiro com a Rua José Val; sendo feita a abordagem. O réu trazia um microtubo de cocaína, além de R\$ 67,00 em dinheiro e seu telefone celular. Perguntado, o acusado admitiu que a droga que levava lhe pertencia e seria destinada à venda, pois atravessava dificuldades financeiras e precisava ganhar dinheiro. Inquirido se mantinha mais entorpecentes

em casa, ele informou que lá havia outras três porções de cocaína. Assim, foi conduzido ao imóvel onde o próprio réu apontou uma caixa de medicamento que estava sobre uma viga de madeira da varanda frontal, onde estava guardada a droga (outros 15 eppendorfs de cocaína). Na estante da sala foram encontrados R\$ 300,00 que o réu disse ter conseguido na venda de cocaína. Ele disse que vendia cada pino de cocaína por R\$ 20,00 e que já havia comercializado diversas porções naquele dia, de onde veio o dinheiro apreendido. O réu era alvo de constantes notícias de tráfico de drogas, mas em abordagens anteriores, embora trouxesse dinheiro, não levava entorpecentes.

Na fase judicial, a testemunha Eder (fls. 137 e mídia), policial militar, afirmou que estava em serviço com o PM Queiroz, quando receberam várias notícias, via Copom, de que "Claudião" estaria traficando drogas próximo ao Bar do Mário. Por isso, os policiais se deslocaram, várias vezes, ao local, por volta das 18 horas, mas nada localizaram. Ao depois, por volta das 21 horas, nova notícia foi recebida de que o réu estivesse traficando drogas no local; e, feita diligência, o réu foi localizado e abordado na esquina da Rua Jose Val com a Avenida do bairro Nosso Teto, exatamente perto do Bar do Mário; estando o acusado com o punho cerrado; e, quando abordado, verificou-se que, nessa mão, o réu trazia um pino cocaína na cor laranja, e assumiu que este pino se destinava à venda. Em busca pessoal, havia R\$ 67,00 no bolso de roupa do acusado, além de um telefone celular. Indagado se teria mais droga (porque as informações recebidas pela Polícia Militar eram de que o réu pegava a droga na casa e entregava na rua), o acusado admitiu que haveria mais drogas em sua casa; e o próprio réu levou os PMs até sua casa, indicando onde estava o restante da droga, na varanda da casa, sobre uma viga, dentro de uma caixinha de remédio, onde havia mais 15 pinos de cocaína com mesma cor da droga localizada no corpo do réu. Indagado se havia mais droga na casa, o réu negou; havendo somente dinheiro que se achava numa estante, que o próprio réu disse provir do tráfico; o que também foi apreendido. Por isso, foi dada voz de prisão ao réu, que foi apresentado no plantão policial. Antes do dia do fato, havia várias notícias que recaíam contra o réu pela prática do tráfico de drogas; uma vez que, depois das prisões de um filho (Pablo) e uma filha do réu (Pietra), o acusado estaria a vender drogas para complementar sua renda. O próprio réu admitiu aos policiais a venda de droga para complementar sua renda em casa. Pelas informações, fazia de dois a três meses que o acusado estaria na venda de drogas nesta cidade. A prova, portanto, forma um conjunto harmônico, que permite relacionar o acusado com a posse e guarda das drogas para sua venda ilícita.

O réu já era indicado, à Polícia, exatamente por vender drogas nas proximidades daquele bar, mediante entrega de droga que ele pegava em sua casa, nas proximidades do estabelecimento comercial. No dia dos fatos, o réu foi abordado trazendo exatamente uma porção de cocaína na mão; admitiu que venderia a droga, e até indicou à polícia onde estavam outros 15 eppendorfs que foram apreendidos em sua casa; além de admitir que o dinheiro apreendido era proveito da venda de cocaína realizada naquela data.

Cumpre anotar que, segundo as testemunhas, o réu era indicado, há tempos (dois ou três meses), pela venda de drogas, e, inclusive, que seus filhos estavam presos também pela prática do tráfico de entorpecentes; e que o réu iniciou a traficância para complementar a renda de sua casa (pois a renda familiar era, outrora, complementada pelos filhos do réu, que traficavam entorpecentes).

Ademais, o réu confessou a finalidade do tráfico da droga apreendida e informou aos policiais até mesmo o valor praticado no comércio da droga; admitindo que o dinheiro apreendido era proveito desse comércio.

Em juízo, embora de forma parcial, o acusado também admitiu que venderia ao menos parte da droga apreendida; o que indica confissão da prática do tráfico de droga. Portanto, consideradas a confissão, as informações policiais sobre a forma de agir e a apreensão de droga e de dinheiro com o réu; é evidente que a cocaína se destinava à comercialização ilícita.

Não há vícios, formais ou materiais, na prova produzida, pois nenhum motivo teriam os policiais para simular fato inexistente contra o acusado.

Como é cediço, toda pessoa pode ser testemunha no processo penal (art. 202 do

Código de Processo Penal) e seria incoerente e ilógico que o Estado atribuisse ao agente público policial a tarefa de exercer a atividade de polícia ostensiva, e, ao mesmo tempo, proibisse que esse agente figurasse como testemunha na ação penal. O tráfico de drogas geralmente ocorre em ambientes clandestinos e somente na presença de usuários e de outros traficantes; de forma que seria praticamente impossível a obtenção de testemunhas alheias aos quadros policiais. E, como se sabe, em pontos de venda de drogas, opera a “lei do silêncio”.

Não seria razoável que policiais saíssem à procura de pessoas inocentes para imputação de crimes não cometidos ou para a formação de flagrante “forjado”; principalmente porque, no caso, policiais e réu não tinham qualquer problema de inimizade, e, como é cediço, policiais desonestos usam as drogas que têm para vender, e não para prenderem pessoas inocentes.

A valia dos depoimentos policiais é inquestionável, pois seria extremamente contrário à lógica que o agente escolhido de forma criteriosa para integrar os quadros do funcionalismo público na repressão de delitos venha a ter o valor de seu depoimento diminuído tão-somente por essa condição.

Conforme magistério do Desembargador Xavier de Aquino, “seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito”

(Apelação nº 1.002.771/3, SP, 11ª Câmara). Ainda, consoante o Desembargador Luiz Ambra, “a simples condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita.”.

Como já se decidiu:

[...] é de ter em conta que nos locais em que ocorre o tráfico de entorpecentes, opera a lei do silêncio, razão pela qual é extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes. Vale ressaltar, ainda, que policiais não costumam sair a trabalho portando entorpecentes tão somente pelo prazer de incriminar inocentes desconhecidos. Policiais desonestos venderiam a droga e não a utilizariam para prejudicar terceiros. (TJSP, Apelação Criminal nº 990.08.053842-0, 6ª Câmara Criminal, Rel. Machado de Andrade, J. 06/11/2008).

Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000943-39.2011.8.26.0549, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, J. 04/12/2012).

O tráfico de drogas pode ser provado por diversas formas; especialmente pelas circunstâncias da prisão, natureza e quantidade da droga, e condições pessoais e econômicas do agente (art. 28, § 2º, Lei 11.343/06). O crime é demonstrado por vários indícios, como a quantidade de drogas, forma de embalagem, natureza da substância e pela prova testemunhal. Cuida-se de infração essencialmente clandestina; sendo dispensada a prova do efetivo comércio, desde que apontada a finalidade mercantil por qualquer meio de prova. Assim, pela quantidade, variedade, maneira de acondicionamento das drogas e pelas condições sociais e pessoais do réu, o fato se tipifica no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Note-se que a lei penal incriminadora não exige a ocorrência do efetivo comércio (tradição) para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta guardar, trazer consigo ou ter em depósito, com a finalidade que não seja o uso próprio para que o crime se consuma. A lei penal pune a mera finalidade (intenção) de entrega a terceiros (ainda que gratuita) da posse e da guarda da droga como tráfico consumado.

Ainda que se admita que o acusado seja usuário e/ou viciado em drogas, essa condição não afasta a de traficante; sendo muitíssimo comum (e até a regra) que viciados trafiquem entorpecente para o sustento do vício; principalmente nos casos em que o agente não tem atividade lícita de vida que lhe garanta recursos para a aquisição das drogas que consome.

Procede-se à fixação das penas, na forma dos artigos 68 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Como o réu é primário e sem antecedentes, colaborou com as investigações e a quantidade de drogas não era especialmente expressiva; fixo a pena-base no piso legal, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a confissão espontânea como atenuante; porém, sem efeito na dosimetria da pena, por já estar fixada no piso legal (Súmula 231, Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, viável a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; uma vez que o réu é primário, não possui antecedentes criminais, não se dedicava continuamente à prática delitiva, e era “pequeno traficante” e colaborou com a Polícia Militar, confessando a finalidade mercantil da droga e até indicando à Polícia Militar onde guardava o restante da cocaína em sua casa; de modo que faz jus ao benefício penal.

Ainda que o réu traficasse drogas há dois meses (ou uma pouco mais), observa-se que esse fato não seria impeditivo à concessão do benefício, pois a lei não exige que o agente trafique uma única vez para que faça jus ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Tratando-se de acusado primário, sem antecedentes criminais, e “pequeno” traficante, e como o vulto da atividade foi de pequena dimensão; viável a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (pois não há elementos concretos de que o réu integrasse organização criminosa ou que se dedicasse, de forma profissional e continuamente, à traficância).

A finalidade da lei com o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi conferir tratamento penal mais brando aos “pequenos traficantes”, exatamente por entender a norma que a punição desses agentes de menor periculosidade deve ser mais tênue; uma vez que a difusão da prisão longa de traficantes menores não repercute relevantemente na redução do tráfico de drogas e não gera danos às organizações criminosas.

Este Juízo entende que o benefício do “tráfico privilegiado” não se aplica apenas àquele agente que traficou droga uma única vez, pois não é essa exigência feita pela lei penal. Exige-se apenas que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. Ainda que o agente exerça o tráfico de drogas há algum tempo, se sua atividade não indicar integração em organização criminosa e dedicação exclusiva e intensa ao crime, é possível a aplicação do redutor; e, obviamente, a fixação do quantum de redução da pena deverá observar a natureza e quantidade de drogas e o tempo em que o agente exerceu esse ilícito, pois, do contrário, o benefício penal seria praticamente inaplicável.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação (ou não) do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação do índice (fração) de diminuição da pena devem observar a quantidade e a natureza da droga, as circunstâncias do delito e até mesmo a habitualidade do envolvimento do agente com o narcotráfico. Segundo o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. O legislador ao instituir o referido benefício, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (RHC 72.118/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, J. 20/10/2016, DJe 26/10/2016 e AgRg no REsp 1442055/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, J. 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

Considerando que a quantidade de droga não era especialmente alta e que seu valor de mercado não superaria um salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, mas que havia informações policiais (notícias anônimas) que indicavam que o acusado comercializava drogas há (pelo menos) dois meses; reduzo as penas de três quintos,

fixando-as em dois anos e de reclusão, e duzentos dias-multa.

A pena de multa é fixada no piso legal (art. 43, Lei nº 11.343/06).

A pena reclusão deverá ser cumprida no regime inicial aberto.

O Supremo Tribunal Federal declarou, por seu Plenário, que o crime de "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), não é equiparado a hediondo (STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, J. 23/06/2016). Portanto, não se aplicam os ditames da Lei nº 8.072/90 à espécie. Essa conclusão foi reforçada e prevista na legislação pelo advento do art. 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 (introduzido pela Lei nº 13.964/2019).

Além, disso, o mesmo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ES, relatado pelo Min. Dias Toffoli, reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 (que determina o regime inicial fechado como obrigatório na pena dos autores de crimes hediondos ou equiparados) – abrindo-se a possibilidade da fixação de outros regimes (mais brandos), de acordo com a quantidade de pena aplicada, gravidade do fato e condições pessoais do acusado (art. 33 e §§ do Código Penal).

Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em Repercussão Geral, reafirmando sua jurisprudência, que o regime inicial fechado de cumprimento de pena não é automático ou necessário pela mera hediondez ou pela gravidade genérica do crime; devendo-se observar o disposto no art. 33 do Código Penal para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para autores de crimes hediondos ou equiparados (ARE 1.052.700, Plenário Virtual, Rel. Min. Edson Fachin, J. 03/11/2017).

A lei processual determina que o Juiz observe a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mormente em casos de Repercussão Geral (art. 927, III, CPC):

Art. 927. Os juizes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça não aceitam a aplicação obrigatória (ex lege) do regime fechado nem mesmo para autores de crimes hediondos com fundamento exclusivo na hediondez do delito (exigindo-se, sempre, fundamentação idônea, caso a caso, para a fixação do regime de cumprimento de pena, não bastando a mera alegação de gravidade genérica que o tráfico de drogas traz à sociedade e aos usuários de entorpecentes).

Considerando a natureza do crime, a primariedade do réu, a quantidade e natureza da pena aplicada e as circunstâncias judiciais, o regime aberto se revela suficiente à punição e ressocialização do agente; não se justificando regime mais severo.

Ainda, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal e consoante entendimento tranquilo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; afigura-se viável a aplicação de penas alternativas na espécie.

Assim, considerando a natureza e quantidade de pena privativa de liberdade substituída, a natureza do crime (tráfico de drogas), a primariedade e ausência de antecedentes criminais do réu; substituo a pena de reclusão pelo pagamento de uma prestação pecuniária de um e meio salário-mínimo nacional (vigente ao tempo do pagamento) em favor da Santa Casa de Santa Rosa de Viterbo, e por uma multa vicariante de quinze dias-multa (sem prejuízo da multa principal) no valor unitário mínimo. A quantidade um pouco superior ao mínimo das penas aplicadas se justifica em razão do tempo em que o réu traficava drogas (dois ou três meses), e do fato de dele já ter vendido mais de R\$ 360,00 de drogas até então.

Reitera-se que, para fim de benefícios penais e de execução criminal, o crime ora julgado não é hediondo ou equiparado (art. 112, § 5º, Lei 7.210/84; e STF: HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J. 23/06/2016).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia, para condenar CLÁUDIO ROGÉRIO DO NASCIMENTO, vulgo "Claudião", qualificado às fls. 19 e 138, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto (crime comum e réu primário), e ao pagamento de duzentos dias-multa no valor unitário mínimo; substituída somente a pena privativa de liberdade (reclusão) pelo pagamento de uma prestação pecuniária de um e meio (1,5) salário-mínimo nacional vigente ao tempo do pagamento (em favor da Santa Casa de Santa Rosa de Viterbo) e pelo pagamento de multa substitutiva de quinze dias-multa no valor unitário mínimo (sem prejuízo da multa principal).

Diante das penas ora aplicadas e do fato de o réu ter permanecido em liberdade, faculta-se o direito ao recurso em liberdade.

Em relação ao dinheiro apreendido (fls. 11 - R\$ 367,00), por se tratar de proveito do crime, determino seu perdimento em favor do Funad (Fundo Nacional Antidrogas). Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à transferência do valor apreendido nos autos.

Em relação ao telefone celular apreendido, determino sua restituição ao réu. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, no valor de cem Ufesps. Observo, porém, que o acusado tem justiça gratuita, e, portanto, são inexigíveis as custas e despesas processuais na espécie.

Com o trânsito em julgado da condenação, comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Juízo das Execuções Criminais, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados, intimem o réu para pagamento, no prazo de trinta dias, das penas de multa (principal e substitutiva) e de prestação pecuniária; sob as penas da lei.

Não havendo divergência sobre a natureza do entorpecente apreendido, determino sua destruição. Oficie-se à autoridade policial para destruição imediata das drogas e das contraprovas.

P. I. C.

Santa Rosa de Viterbo, 23 de maio de 2022.

Alexandre Cesar Ribeiro
Juiz de Direito
(assinatura digital)